壹、拋棄繼承

一、拋棄身分权（繼承权屬身分权）

1.未滿7歲：无行為能力⇒身分行為不得代理之例外，由法代代理之

2.非為子女利益拋棄而代為拋棄⇒應選任特別代理人（§1086Ⅱ）

(1) §1088Ⅱ但 說：非為子女利益處分特有財產，實務採无效說（司法行政部60.12.3台60函民決10043號函、60.1.7台60函民166號函、54.6.29台54函民3716號函）

(2) 林：代理拋棄非處分，若顯以損未成年子女利益為主要目的則屬代理权之权利濫用（§148Ⅰ）⇒應為无权代理

3.7~18歲：拋棄須法代同意（林、SC 69台上2041例）

二、性質

1.以法院為特定人之單獨行為說（戴）：§1174Ⅱ明文

2.无相對人之單獨行為說（通、SC 62.2.20第1次民庭決議）：雖須向法院為之，法院仍非相對人，可參見立法理由

三、不得撤回（通、司法院76.8.14(76)廳民三2718號函復台高院研究意見、44台上1257例）

1.雖法院非相對人，仍須到達法院始生效力⇒類推§95但 先時或同時抵達撤回有效

2.§92詐欺脅迫 有適用，為避損及他人利益，撤回之程序應同§1174Ⅱ、Ⅲ（林、戴、楊）

四、不得附期限及條件：法无明文，若允許之將使繼承人資格未定，解釋上應否定之（林、戴、楊、史、司法行政部54.6.29台54函民3714號函、SC 23上2683例）

五、不得一部拋棄：若專就某权利之拋棄則屬財產权上之拋棄（通、SC 67台上3448例、3788例、65台上1563例）

↳財產权拋棄迥異處：係財產行為、无時效、无須書面（§758Ⅰ仍須登記）、无§1176-1之管理義務、无§1175溯及效力（林、SC 106台上1650）

六、要件（§1174Ⅱ、Ⅲ）

1.繼承人始得為之

(1) 有前順序之人，後順序人无從拋棄，喪失繼承权之人自无從拋棄

(2) 代位繼承人可拋棄，再轉繼承人因繼承权為身分权一身專屬不得繼承，故不得對第一繼承為拋棄

2.於法定期間內為之：§1174Ⅱ 知悉繼承時起3月內

(1) 可推知繼承開始前不得預先拋棄繼承，因其尚未得知自己得繼承，不符法定期間（SC 22上2652例）

(2) 司院解3845：3月後所為之拋棄不生效力

3.書面向法院為之⇒要式行為，違者§73无效

4.§1174Ⅲ為例示規定，非要件（通、SC 107台上1110裁）

5.向有管轄权法院拋棄（家事§144Ⅰ被繼承人所在地法院）：向无管轄权法院拋棄不生效力，拋棄合法者法院須行家事§132Ⅱ

七、效力

1.拋棄人

(1) §1175溯及繼承開始時生效⇒自始非繼承人

(2) 拋棄者係繼承权，非財產上权利義務（§1174Ⅰ），拋棄前所承受之权利義務之消滅係附屬效果

(3) §1176-1 拋棄前有管理遺產者，应負具体輕過失責任繼續管理直到他人开始管理

(4) 代位撤銷以保全債权（§244）

A、肯定說（戴東雄、戴修瓚、王伯琦、孫森焱，邱聰智、鄭建財、SC 69台上847）

(A) 繼承效力具物权性質，而拋棄則有積極創設之性質，使已有之財產由有变无→无異就其財產為单独无償处分

(B) 若採否定，对其他繼承人錦上添花，肯定說相当对債权人之雪中送炭→公平原則；利益衡量，雪中送炭＞錦上添花，呼应当然繼承主义

B、否定說（鑑、林、鄭玉波、史、歐陽經宇、胡、振、棋、SC 69台上1271、73第2次民庭決议）

(A) 拋棄係身分行為，对於单方面給予財產利益加以拒絕係人格自由尊嚴之表現（拋棄繼承係当然繼承之產物，輔助實現前述法律原則）

(B) 身分行為雖对債权人不利，仍不得撤銷，§244限非以其人格法益為基礎之財產上行為

(C) §244係防止債权人不当減少其責任財產，保留原有資力，拋棄繼承僅未增加資力而已，非減少責任財產

(D) 拋棄溯及繼承开始時生效→一但拋棄則自始脫離繼承人地位，无既得利益可言

(E) 債权人所信賴者為債務人個人財產，对於債務人繼承財產之期待利益不值保护（与被繼承人之債权人对繼承人之固有財產相同）

2、其他繼承人（§1176）：74修法前條文不明→劃一說、兼採劃一說与分股說、繼承人不存在說；修法後明文列举

Ⅰ、应繼分歸屬他繼承人→无法代位繼承，第一順位应繼分由他繼承人平均分受

Ⅱ、第二至四順位应同§1144②、③→林戴：Ⅰ、Ⅱ文字上有劃一說兼採分股說色彩，但立法理由似以繼承人不存在說為基礎

Ⅲ、无後順序繼承人僅剩配偶由其全权繼承

Ⅳ、配偶拋棄，应繼分歸屬於血親繼承人

Ⅴ、第一順位親等近全权拋棄者由次近親等之直血卑繼承

Ⅵ、先順序人均拋棄由後順序繼承，後順序无人或不明準用无人承认繼承之規定

3、代位繼承人中有人拋棄：应繼分歸屬其他代位繼承人，全体拋棄則歸屬其他繼承人（戴、林）

(1) §1140係基於子股之独立而不流通，应有其適用，若採劃一說將違立法目的

(2) 林：可以繼承人不存在說解釋之（§1176修正理由）

(3) 林：§1176掛一漏萬，且修法理由明採繼承人不存在說，应仿JP§939明訂自始非繼承人，刪§1176

貳、无人承认之繼承

一、場合：繼承人有无不明

1、繼承人所在不明或生死不明⇒依家事§142~153失蹤人財產管理事件辦理，非繼承人有无不明（通）

2、§1176Ⅵ 次順序人不明或全权拋棄繼承

3、无繼承人

(1)直接歸屬國庫說（范揚、劉鍾英）：无須再行特別程序

(2)成為无主財產說（鼎、胡）：歸屬國庫或允許他人先占（§802）

(3)仍須管理清算說（戴、棋、林、22院898）

A、§1177、1179仍應踐行，§1178搜索似无適用餘地，為求慎重，仍應踐行

B、TW民法、戶籍法未配合，繼承人之无記載不代表无繼承人，登记非繼承要件⇒无繼承人与繼承人不明事實上難區別，仍應搜索

4、唯一繼承人之存在有爭執：養子一人，其他親屬爭執收養权或喪失繼承权，非繼承人有无不明，應承认其繼承权

5、戶籍无記載 惟有自稱繼承人出面而資格尚未確定

(1)準用无人繼承管理說（戴）：非无人繼承，惟若僅有一人仍有管理遺產之必要，應準用无人繼承規定加以管理（批評：若已歸國庫則極為不利）

(2)準用失蹤人財產管理說（史）（批評：非失蹤）

(3)折衷說（林）：類推无人承认繼承進行管理，惟於判決確定前不進行搜索，以保障債权人及繼承人之利益

二、遺產管理人

1、選任

(1)§1177親屬會议，74修法前无1個月規定，惟逾期仍合法，法院不得依此理由駁回，仍應行公示催告

(2)§1132② 召集或決议有困難⇒声请法院選定、§1178Ⅱ逾期或无親屬會议利害关係人或檢察官得声请法院選任遺產管理人（院1107：无親屬得声请指定）

(3)利害关係人：繼承人之債权人、受遺贈人、稅捐稽徵机关（遺贈稅§6Ⅱ）

(4)§1178-1 選定前法院得因利害关係人及檢察官之声请為保存遺產之处置

(5)資格（家事§134）：限自然人，且无Ⅱ之消極條件

(6)可選任自可解任之（通）

2、职務

(1)§1179Ⅰ① 編製遺產清冊：就職三月內編製（§1179Ⅱ前），此係完成時限，編製所需費用屬管理費用，由遺產支付之（§1150）

(2)§1179Ⅰ② 保存遺產必要之处置：管理行為係指不變更物或权利性質之保存、改良或利用等，不含处分行為，惟必要处置應含變价处分，无須經同意

(3)§1179Ⅰ③ 对債权人及受遺贈人公告之声请与通知：同§1157惟公示催告為1年以上，且應通知因§1182將使其蒙受不利益

(4)§1179Ⅰ④ 清償債权及交付遺贈物

A、§1181不得於§1179③所定期間內清償或交付遺贈

B、司法院(81)厅民2字13793：縱声请強執，於公示催告期間屆滿前不得強執，已开始者應暫停

C、§1179Ⅱ中 債权清償先於遺贈，优先权性質应先於普通債权，不足应按比例償还，不待明文

D、§1182 未報明之債权人与受遺贈人僅得就賸餘財產行使其权利

E、已知債权人或受遺贈人未報明者，是否有§1182

(A)肯定说（胡、劉含章）：管理既已通知，債权人不報明屬咎由自取，僅能就賸餘財產受償（批评：过苛，忽视債权人保障）

(B)否定说（鼎、范揚）：依JP、§1162，既已明知，应按比例清償 ⇒ 應与§1162同一解釋

(C)折衷说（戴、棋、林）：未明文即不能同樣解釋，因§1159明文未及於受遺贈人，故債权人適用§1159，受遺贈人§1182

F、未盡通知义務致債权人或受遺贈人受損害，应負損害賠償責任（史、林）

G、§1179Ⅱ後 為清償債权或交付遺贈物之必要，管理人經親屬会议之同意，得变賣遺產

(A)依債施§28為之

(B)无法召开或有困難，应声請法院裁定同意代替

(5)§1179Ⅰ⑤移交

A、繼承人承认並能確认其身分時，应移交遺產，承认非指单純或限定承认，係指其為繼承人之身分

B、§1185无人繼承，清償及交付遺贈後，如有賸餘，歸屬國庫，不為履行時國庫自得向法院提起履行之訴（31院2295）

(6)§1180遺產狀況之報告或说明：方式不限，口頭或書面皆可

(7)注意义務

A、以有无報酬 適用§535有報酬抽象輕過失，无報酬具体輕過失说（戴、胡、范揚）：此係一般法理应直接適用

B、抽象輕過失说（史、棋、林）：家事§151 準管理人注意 + §1183明定報酬請求权 + 家事§135② 違背善良管理人注意义務 法院得依利害关係人声請解任

(8)§1183報酬

A、法院酌定，必要時得命声請人先行定之

B、林：命自行墊付於理不適，又報酬屬管理遺產所生費用，故应由遺產支付之（104 §1150修正理由）（SC101台上234、99台上408）

3、法律上地位

(1)舊法：法人（大清民律草案繼承法§96、15民國民律草案、17繼承法草案

(2)§1184：有承认者，管理人於承认前之職務上行為屬代理

A、代理人说（棋、振、羅鼎）：用以擬制為繼承人之法代

B、法定任務说（戴、林、台中高分院104上467）：不过為保护交易安全，不許繼承人否定管理人於職務上所為行為，非真正代理人，乃將其行為效果擬制於繼承人而已

↳ 林：主观上非代理繼承人為之，客观上非以本人名义，与顯名代理主义相違，況且繼承人不存在時將為何者之代理人易生問題

三、搜索（§1178）

1、81.2.27（81）廳民字02696號函覆台高院：遺囑執行人仍应依§1187，不能逕向法院声請

2、公示催告 ⇒ 法院依職权為之

(1)法院催告承认繼承（§1178）：先，6月以上

(2)法院催告債权人与受遺贈人報明債权及声明願受遺贈（§1179Ⅰ③）：後，1年以上

3、公示催告後清算終結前承认人之效力

(1) Ger §1165、JP §958-2 明文不得再主張权利

(2) TW 未明文，否应張從 Ger、JP，但探条係保护繼承人，即避免无主物之立法目的，採前说國与民爭利之嫌 (林、內政部82.4.15台內地8279019号函)

四、賸餘財產

1、立法例

(1) Spain §956 國家為繼承人、Ger §1936 所屬邦之公庫為繼承人、Swizz §466 歸屬地方自治团体

(2) JP §959、奧地利(Austria) §760、TW §1185 歸屬國庫之立法主义

2、30院2213

(1) 國庫因 §1185 对遺產有期待权 ⇒ 係 §1129 所称之利害关係人

(2) 由管轄繼承人住所地之地方行政官署接收

(3) 於清算後如有剩餘当然歸屬國庫，不以除权判決為生效要件，因 §1178 非当事人声請公示催告，僅法院依此程序公告，故无從声請除权判決

3、非因法律行為移転 ⇒ 動產无須交付，不动產不待登记 (§759)

4、遺產管理人依 §1179Ⅰ⑤ 移転，並為管理之计算，於交付前依善良管理人注意保管之 (林、史)

5、31院2299：移転範圍含物权及債权，強執程序应繼續執行，由國庫享執行利益

6、无体財產权 (智慧財產权)：无人繼承即消滅 (商标 §39、專利 §66、著作权 §42①)

7、取得之性質

(1) 原始取得说 (通)：歸屬國庫後係原始取得，不得再对國庫行使权利

↳ 范揚：採此说但认对权利人过苛

(2) 折衷说 (史)：積極財產上負担仍同原始取得消滅，惟時效取得未登记、租賃权以繼受取得為宜

(3) 得对國庫行使权利说 (林)：§1182 明文仍得对賸餘財產行使权利 ⇒ 权利未消滅僅為減弱而已，若认原始取得則架空 §1182

↳ 避免國与民爭利，宜解為債权人或受遺贈人於賸餘財產範圍內仍得对國庫行使其权利